

1502455-73.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... absolvição de ambos em relação ao tráfico por falta de provas; c) absolvição de ambos quanto à associação para o tráfico, por falta de materialidade e de provas quanto à estabilidade e permanência; d) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a VALDINÉIA para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas, pois ela seria responsável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502455-73.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502455-73.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260895/2021 - 09º D.P. GUARULHOS, 20446561 - 09º D.P. GUARULHOS, 1711/21/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2260895 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NEYTHAN JACINTO DE ANDRADE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

NEYTHAN JACINTO DE ANDRADE e VALDINÉIA SILVA CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

1) desde data incerta até o dia 23 de setembro de 2021, por volta das 14:00 horas, na Rua Joaquina de Jesus, nº 571, Taboão, os denunciados e um indivíduo menor de idade não identificado, associaram-se, com permanência e habitualidade, para o fim

de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas;

2) no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 14:00 horas, na Rua Joaquina de Jesus, nº 571, Taboão, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, os denunciados e um indivíduo menor de idade não identificado, agindo em concurso e unidade estável de desígnios, vendiam e guardavam, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 50 eppendorfs de crack, com massa líquida de 9,96g, 96 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 99,45g, 42 invólucros contendo maconha, com massa líquida de 90,61g, 12 porções de maconha, com massa líquida de 5,22g, 24 porções de maconha, com massa líquida de 2,91g, 36 porções de cocaína, com massa líquida de 13,12g, drogas que causam dependência física e psíquica, além de R\$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) em notas diversas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/33, laudo de constatação provisório de fls. 13/22 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado.

De acordo com a denúncia, na época dos fatos, os denunciados e um indivíduo menor de idade não identificado, associaram-se para o cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas pela região, ficando estabelecido que o denunciado NEYTHAN seria o gerente, encarregado pela venda das drogas, determinando como se daria a venda pelo indivíduo menor de idade que se encontrava no local, exercendo a função de "sacola". Por sua vez, VALDINEIA seria a responsável por avisar a presença de policiais nas redondezas e auxiliar os agentes do tráfico, recebendo, por isso, a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) por semana.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, os denunciados se deslocaram ao local indicado anteriormente e iniciaram as suas operações destinadas ao tráfico de drogas; nesse contexto, os denunciados guardavam no local e realizavam a venda de entorpecentes para terceiros com o modus operandi delimitado no parágrafo anterior, porém policiais que faziam patrulhamento velado em virtude de denúncia quanto ao tráfico de drogas realizado em apartamentos da região visualizaram os denunciados e um indivíduo menor de idade conversando no local apontado na denúncia e resolveram agir. Ainda narra a denúncia que, passando-se por usuário, o policial civil José Aguibson Soares da Silva fez questionamentos sobre a venda de drogas, perguntando "se está tendo" e dizendo que "gostaria de um mato", uma porção de maconha, respondendo o denunciado NEYTHAN positivamente; o denunciado NEYTHAN então saiu para buscar as drogas e voltou com uma mochila nas costas, saindo para de trás dos prédios com o indivíduo menor de idade não identificado, solicitando que o policial, que se passava por usuário, aguardasse.

Descreve a denúncia que ao retornar, o policial deu voz de parada, momento em que NEYTHAN tentou evadir-se do local, sem sucesso; já o indivíduo menor de idade conseguiu empreender fuga, por sua vez, a denunciada VALDINEIA, que realizava a função de olheira, também foi presa em flagrante. Ainda descreve a denúncia que, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas NEYTHAN acabou informando que as drogas estariam guardadas em um buraco nas proximidades, dentro de uma sacola plástica, assim como em sua residência, cuja entrada foi franqueada aos policiais por sua genitora; na casa do denunciado, além de uma grande quantidade de drogas, foi encontrada a quantia de R\$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) em notas diversas, proveniente do tráfico.

Perante a Autoridade Policial, prossegue a denúncia, NEYTHAN confirmou a traficância, tendo a função de gerente, e a participação de VALDINEIA na empreitada criminosa, ficando esta responsável por avisar a atuação policial na área e outros auxílios, ganhando cerca de R\$ 1.000,00 por semana (fls. 12), sem indicar quem os havia cooptado para aquele trabalho ou seria responsável pelos entorpecentes. Já a denunciada VALDINEIA negou envolvimento no tráfico, mas confessou que avisava NEYTHAN sobre a presença de policiais no endereço por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, desempenhando a função de olheira (fl. 11). Conforme a denúncia, os delitos foram cometidos durante o estado de calamidade pública resultante da pandemia do Covid-19.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada a notificação dos acusados (fls. 107/108).

O réu Neythan foi devidamente notificado (fl. 157) e apresentou defesa preliminar às fls. 161/163. A ré Valdineia foi devidamente notificada (fl. 167) e apresentou

defesa prévia (fls. 170/172).

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 e mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu Neythan sendo designada audiência de instrução para o dia 04 de abril de 2022 (fls. 175/177).

O réu Neythan foi citado e intimado (fl. 222).

Em audiência, a acusada foi citada; foram ouvidas duas testemunhas, a denúncia foi aditada para incluir a causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e realizado o interrogatório dos réus, manifestando-se as partes, ao final, tudo conforme registrado em termo de audiência e respectiva gravação audiovisual.

O Representante do Ministério Público requereu a procedência parcial, apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, não havendo provas suficientes quanto ao crime de associação.

A Defesa requereu: a) nulidade do processo desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais; b) absolvição de ambos em relação ao tráfico por falta de provas; c) absolvição de ambos quanto à associação para o tráfico, por falta de materialidade e de provas quanto à estabilidade e permanência; d) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a VALDINÉIA para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas, pois ela seria responsável apenas por atuar como "olheira"; e) a fixação das penas-base no mínimo legal, diante da primariedade de ambos e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; f) atenuantes da confissão informal e da menoridade relativa de NEYTHAN; g) reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), em sua fração máxima, para ambos, primários; h) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas para NEYTHAN, pois segundo os policiais foi ele quem indicou onde estavam os entorpecentes, colaborando para a recuperação do produto do crime, bem como confessou extrajudicialmente a traficância; i) o afastamento da causa de aumento imputada, pois não configurada; j) a fixação de regime inicial diverso do fechado para ambos; k) a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP; l) justiça gratuita; m) recurso em liberdade para ambos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, não prospera a tese de que as provas seriam nulas em razão da violação de domicílio por parte dos policiais. Assim concluo porque, apesar da existência de alguns julgados em sentido contrário da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, tanto a 5ª Turma deste mesmo Tribunal quanto a 1ª Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal, em decisões recentíssimas, reafirmaram o entendimento de que, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, estaria autorizado, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta

a via eleita.6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF -1ª Turma - Ag. Reg. no RHC nº 213.852/RJ - Rel^a. Min.Rosa Weber - D.J. 30/05/2022)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIMENO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FUGA DO AGENTE, TENTATIVA DE SE LIVRAR DAS DROGAS E RESISTÊNCIA À PRISÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, MUNIÇÕES, PETRECHOS DO TRÁFICO, SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO. INGRESSO DOMICILIAR. HIPÓTESE LEGAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. II - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram o recorrente portando uma mochila conversando com uma pessoa dentro de um carro. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os agentes empreenderam fuga, tendo o recorrente adentrado sua casa e atirado a mochila para o terreno vizinho. Ao ser alcançado, o recorrente ofereceu resistência, ao passo que sua mochila foi recuperada, na qual foram encontrados "R\$ 15.956,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais); uma caixa contendo 50 (cinquenta) cartuchos intactos do calibre 5.56 (munição de fuzil); 04 (quatro) balanças de precisão; anotações diversas relacionadas ao tráfico de drogas, em 14 (quatorze) folhas; 311 (trezentos e onze) microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo cocaína; 252 (duzentos e cinquenta e dois) pedras de crack; 343 (trezentos e quarente e três) gramas de cocaína a granel em uma embalagem; 115 (cento e quinze) gramas de cocaína em duas embalagens; seis porções menores de cocaína, que totalizaram 18 (dezoito) gramas; 02 (duas) pochetes vazias; 03 (três) rolos de papel filme utilizados em embalagens de drogas e 01 (uma) máquina de cartão". Na mesma esteira, o v. acórdão objurgado reforça que "O auto de prisão em flagrante revelou que os dois policiais, que efetuarão a prisão, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente, o qual, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga, vindo a entrar na sua casa, resistindo à prisão. Certo é que a inviolabilidade do domicílio não é direito absoluto, prevendo a própria Constituição da República hipóteses em que é possível a entrada em residência sem o consentimento do morador, dentre as quais se destaca o caso de flagrante delito. [...] Esta é exatamente a hipótese retratada nos autos, de modo que não se configura a alegada invasão de domicílio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. III - Ao contrário da sustentação defensiva de que "pouco importam" as atitudes do agravante que ensejaram a atuação policial, reforça-se que, não só pela importância da devida tutela jurisdicional no caso em exame, mas também pela compreensão mais ampla acerca da formação social e jurídica que permeia a sociedade brasileira e das regras de convivência que organizam as relações humanas e sociais, as normas penais e processuais penais tutelam os bens jurídicos mais importantes e as fundadas suspeitas de prática delitiva ensejam, por autorização constitucional, a atuação das forças de segurança que tem, por atribuição da própria Carta Magna, o dever de proteção e tutelados bens mais valiosos da sociedade. IV - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso domiciliar, consistentes na fuga e no arremesso da mochila, comportamentos concretos a ensejar fundadas razões para a atuação policial, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de variadas formas de apresentação da cocaína, além de petrechos do comércio espúrio, munições e expressiva quantia em dinheiro, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio e da escorreita atuação policial. V - Ademais, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão

vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -5ª Turma - Ag. Reg. no RHC nº 164.149/SP - Rel. Min. Jesuino Rissato - D.J. 24/05/2022).

A abordagem dos acusados, portanto, não constituiu ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes.

A pretensão punitiva merece parcial procedência, apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, e sem a aplicação da agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal e da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei n.

11.343/2006.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 23/31), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 32/33), Laudo de Constatação (fls. 13/22), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico positivo (fls. 263/266), laudo da mochila (fls. 136/138), laudo dos celulares (fls. 139/151), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, a autoria também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

A testemunha André Ramos Pinto, policial civil, narrou que era um local conhecido por tráfico de entorpecentes, e receberam diversas denúncias anônimas, dando conta de que havia tráfico dentro do condomínio, atrás da torre do condomínio, sendo também denunciados alguns apartamentos como sendo locais de armazenamento de drogas. Fazendo uso de uma viatura descaracterizada, pararam em posição com visão ampla do local. Durante a campana, viram o acusado Neythan chegar, dirigir-se ao bloco 2, e ali conversar com a acusada, também na companhia de um menor de idade. Seu parceiro José Aguibson foi em direção a essas pessoas, verbalizando como se fosse comprar entorpecentes, então Neythan pediu para ele aguardar, nisso ele se afastou, junto com o menor de idade. Ficou acompanhando tudo de dentro da viatura. Neythan retornou cerca de meia hora depois, e seu parceiro permaneceu aguardando, conforme pedido. A ré foi até o encontro dele e disse para não ficar ali na frente do prédio, para não chamar a atenção, então seu parceiro se afastou um pouco mais. De dentro da viatura, junto com outro parceiro, mantiveram contato visual o tempo inteiro. Neythan se dirigiu ao fundo dos prédios e o menor foi ao encontro dele; quando Neythan retornou com a bicicleta, seu parceiro foi em direção a ele, deu voz de parada, ele tentou empreender fuga, mas caiu. Foram ao encontro deles; o menor já estava pulando o muro do condomínio; Neythan assumiu que foi buscar o entorpecente e os levou até o local onde estavam; havia cocaína e maconha. A ré ficou ali próximo, parada. Quando indagado se havia mais coisas em sua casa, Neythan respondeu que sim, inclusive dinheiro proveniente de prévias vendas. A denúncia falava que faziam uso do apartamento da ré, mas ela alegou que ali nada havia. Ela franqueou a entrada ao apartamento, que estava precário, quase não havia móveis. Ela disse que era usuária, e que não estava envolvida com o tráfico, só deixava usarem o apartamento para pegarem água, essas coisas, e que a função dela era avisar se havia policiais ou não. Foram até o apartamento de Neythan; a mãe dele franqueou a entrada; encontraram mais drogas, semelhantes às que estavam no outro local. Não conhecia os acusados. Neythan disse que fazia a função de "gerente", e quem comercializaria os entorpecentes era o menor; a função do Neythan seria abastecer o local. Confirmou que a mãe de Neythan, que estava na casa, após ser explicada a situação, autorizou a entrada, juntamente com Neythan, que mostrou onde estavam as drogas e o dinheiro. As drogas e o dinheiro estavam no interior do quarto, que ele confirmou ser o quarto dele. Havia cerca de R\$ 600,00 em notas trocadas, além de cocaína, maconha e crack. Os outros entorpecentes estavam numa sacola plástica, que Neythan colocou no fundo do condomínio, num buraco, para posteriormente o menor pegar; Neythan que os levou até lá; também eram divididos em porções, tratando-se de cocaína, maconha e crack. Seu parceiro estava próximo do menor e falou com ele; Neythan confirmou que era menor. A ré disse que avisava sobre a chegada dos policiais para quem estivesse ali; disse que conhecia Neythan; havia até o telefone de Neythan no telefone dela, que ela própria mostrou, de livre e espontânea vontade. Ela também mostrou conversas por meio de aplicativos em que ela o avisava sobre a chegada da polícia. Foram apreendidos os celulares. Neythan já fazia o tráfico há bastante tempo, ele já disse que fazia um "tempinho", até

porque já era “gerente”, responsável pelo abastecimento, mas alegou não saber quem era responsável pelo local. A ré disse que fazia isso, mas achava que não havia problema, sendo que disse fazer isso frequentemente. Confirmou que os dois admitiram que não era a primeira ocasião que faziam aquilo. Não se recordou de os réus terem falado os valores que recebiam.

A testemunha Emerson Goularte Gaspari, policial civil, narrou que o local já é conhecido pelo tráfico; havia diversas denúncias no local, mais de meia dúzia, e uns dez dias antes fizeram uma prisão no local. Foram até lá diante da continuação das denúncias, para saberem se conseguiam encerrar o tráfico. No dia, foram até o local e ficaram observando. Neythan chegou de bicicleta e ficou conversando com um menor, que parecia até criança, e com uma senhora pela janela. Acharam estranha a situação. Seu parceiro José se passou por usuário e foi em direção a esses três, começou a pedir drogas, e o rapaz disse para ele aguardar, que iria buscar, pois estava sem drogas naquele momento. Neythan saiu com a bicicleta. Essa senhora saiu de dentro e falou para eles se afastarem um do outro. Ficaram aguardando para ver se o rapaz da bicicleta voltava; ele retornou, passou seu parceiro, chamou o menorzinho, eles foram até o fundo do condomínio, onde nas denúncias se falava que escondiam as drogas, e ficavam ali por alguns minutos. Quando Neythan voltou, seu parceiro deu voz de prisão a ele. Correram para dar apoio. Enquanto detinham Neythan, o menor pulou o muro de trás do condomínio, que fazia divisa para uma escola. A senhora ficou estática, do lado de fora. Ele os levou para o local onde estavam as drogas, no fundo do condomínio, dizendo que a função dele era levar e buscar, e quem iria realizar a venda era o menino que correu. Acharam a droga toda fracionada, pronta para as vendas. Ainda não havia dinheiro ali, pois iriam começar as vendas. Neythan, questionado, confirmou que havia mais drogas na casa dele; a mãe dele franqueou a entrada e mostrou onde estavam as drogas, além do dinheiro proveniente de outras vendas. Não conhecia os acusados. O réu Neythan admitiu que as drogas encontradas no condomínio tinham sido colocadas lá por ele para fins de tráfico; ele também admitiu que as drogas encontradas na casa dele eram para fins de tráfico, ele admitiu que era responsável pelo abastecimento do local, era o “gerente”. Valdinéia ficou um pouco surpresa, disse que só os avisava quando vinha a polícia, que eles usavam o apartamento dela como apoio, para tomar uma água, e disse que era usuária também. Neythan disse que já estava há algum tempo fazendo isso, tanto que ele tinha drogas na residência e dinheiro de vendas anteriores. Não se recordou se Valdinéia afirmou receber dinheiro, ou se era paga com drogas. Os dois afirmaram se conhecer, e a própria denúncia dizia que o apartamento dela estava envolvido com o tráfico, que usavam o apartamento dela para isso. Sabiam que o terceiro indivíduo era menor pela estatura dele, tinha o tamanho de uma criança, praticamente. Neythan disse que o menor faria a venda de drogas. Não comentou se ele já tinha feito isso antes, disse que naquele dia, o menor iria fazer. Havia cocaína, maconha e crack, nos dois locais. Valdinéia chegou a mostrar conversas com Neythan, alegando que apenas avisaria que vinha a polícia. O celular foi apreendido e enviado para o IC. O dinheiro encontrado estava em notas miúdas, mas não se recorda da quantidade; estava tudo na casa dele. Confirma que foram até a casa da ré, ela disse que poderiam entrar, era um local bem precário, com poucos móveis; ali não havia drogas.

A testemunha José Aguiabson Soares da Silva, policial civil, narrou que era um local de sabida traficância, ponto de drogas conhecido no DP, já fizeram prisões anteriores no local. Em razão de algumas denúncias, que chamaram a atenção, fizeram diligência no local, fazendo uso de viatura descaracterizada. Buscaram ponto estratégico que proporcionasse amplo campo de visão. Foi à frente se passando por usuário, usando roupas e jargões do meio. Esse condomínio é uma espécie de CDHU; chegou à torre de frente, onde se encontrava Neythan, sobre uma bicicleta, encostado no muro; ao lado dele havia uma pessoa aparentemente menor, muito mirradinho, e Valdinéia estava numa janela, conversando com o acusado. Disse “e aí, família, tá tendo hoje?”, como geralmente se comunicam. Disseram “faz uma média aí”, o que geralmente se diz para aguardar a chegada das drogas. Neythan saiu de bicicleta, e o depoente ficou conversando com esse menor, que realmente acredita ser menor, pelo tamanho e pela voz. Perguntou “o que está tendo”, e o menor disse

"aguenta aí". A ré, ainda de dentro da janela, com voz de comando, disse "vocês dois aí, parem de arrastar", para não chamarem a polícia para lá. Ela saiu então do apartamento, e disse para saírem de lá, "não arrasta aqui não". Então o depoente se afastou um pouco do menor. Passaram-se cerca de 40 minutos, e Valdineia o tempo todo conversava com o menor, reclamando, "aí arrasta". Falou que tinha pouco tempo, e a própria ré falava "calma, ele já está vindo", assim como o menor. Então chegou Neythan, com uma mochila, ele entrou, passou pelo menor, conversou com Valdineia, e se dirigiu aos fundos do prédio, e disse "espera aí", em voz de comando. Ele deve ter ficado mais uns 3 ou 4 minutos, e o depoente ficou conversando com a ré. Preferiu abordar Neythan, e quando ele veio perto do depoente, deu voz de parada, então ele tentou sair, mas conseguiu contê-lo no solo; nisso, o menor, ao fundo, fugiu. Ao fundo desse condomínio, lateralizado, há uma escola primária, e esse menor conseguiu pular o muro para essa escola. Conseguiram prender Neythan e Valdineia. Mandou que ela ficasse parada, e ela atendeu, até porque morava ali. Neythan disse "já era, perdi, as drogas estão ali", e foram até o local, a droga estava escondida num buraco; só encontraram porque ele apontou onde estavam. Havia pelo menos 100 porções no total, entre cocaína, maconha e crack, todas já fracionadas para venda. Questionado se havia mais drogas na casa dele, ele, de pronto, assumiu, mas afirmou que seus familiares não sabiam. Ficaram preocupados, pois é comum algum transeunte saber e remover as drogas da casa. O apartamento da ré foi denunciado como local de tráfico, e ela permitiu o acesso ao local; em busca acompanhada por ela, não encontraram entorpecentes. Então foram à casa de Neythan, com certa urgência, com receio de alguém tirar as substâncias de lá. Ficou com Valdineia na viatura, enquanto a outra parte da equipe foi à casa de Neythan, onde a mãe dele se mostrou repulsiva, mas autorizou a entrada da equipe, e a conduziu até o quarto dele, onde havia uma quantidade considerável de entorpecente, de tipo idêntico ao encontrado na biqueira, além de cerca de R\$ 600,00 em notas trocadas. Souberam que Neythan estaria na gerência, ou seja, abastece e recolhe, faz o abastecimento dos entorpecentes e recolhe o dinheiro arrecadado; ele que coordenava isso naquele ponto. Ele não disse por quem foi contratado. Foi uma diligência um pouco demorada. Não conhecia os acusados, acredita que nunca os abordou. Não conhecia o menor. Teve certeza de que esse indivíduo era menor, ele tinha voz de criança, e era mirradinho; aparentava ter no máximo 16 anos. Havia uma escola "colada" com esse condomínio, "parede com parede". Acredita que se chegaria à escola apenas beirando a calçada, ao final do muro do condomínio já seria a escola; distância de uns 50m, 70m no máximo. Neythan admitiu que tanto as drogas no condomínio quanto as drogas na casa dele eram para fins de tráfico; ele já estaria há algum tempo no tráfico, coisa de um mês, mais ou menos, até pela função que ele agregava. Tudo levou a crer que ele estava na função de gerente, por armazenar a droga em casa, e pelo que o menor disse, "seguraria a sacola", ou seja, iria efetuar a venda. O menor disse que Neythan iria buscar a droga para ele, e ele venderia. Neythan saiu com a bicicleta e foi até a casa dele, que fica em outra comunidade, tentando estimar a distância, acredita que seja de 3 a 4 quilômetros. Os três estavam conversando muito à vontade, agrupados, falando, porém a ré pelo lado de dentro do apartamento dela, que é térreo. Todo o cenário revelou que a ré estava na função de "campana", que avisa quando chega a polícia, que faz a primeira triagem, até por conta da voz de comando que ela deu ao depoente e ao menor, dizendo "para de arrastar", "vai cada um para um lado". Disse que é típico da traficância que, no ponto de venda de drogas, não se permite que se aglomerem muitas pessoas, para não criar confusão que chame a atenção. Ela ficou totalmente surpresa quando o depoente deu a voz de parada; informalmente, ela disse que avisava quando chegava a polícia, que os deixava comer no apartamento, e por isso acredita que o apartamento dela foi fruto de denúncia; ela tinha essas condutas de coordenar, de não deixar as pessoas ficarem muito lá.

Interrogado, o réu Neythan afirmou que tem 18 anos, mora com sua mãe, irmão, mulher e irmã pequena, informou o endereço, negou antecedentes. Quanto aos fatos, disse que queria permanecer em silêncio.

Interrogada, a ré Valdineia afirmou que tem 49 anos, mora com seu filho, negou antecedentes. Quanto aos fatos, disse que os traficantes nunca entraram na sua

casa; havia usuários, pessoas que passavam, e como deixa a janela aberta, eles pediam um copo d'água e ela dava; Neythan passou pela sua janela perguntando se estava tudo bem, conhecia-o através de uma colega que ficou com ele; um menino que foi preso pediu para avisar ao Neythan, e disse que não faria isso; ele pediu para dar a Neythan o recado de que os policiais tinham levado as drogas; conhecia Neythan fazia quinze dias; usa comprimidos para diabetes e depressão, não é usuária de drogas; os policiais entraram na sua casa derrubando tudo; ficou do lado de fora porque seu apartamento estava como ponto de tráfico, e na sua casa nunca entrou traficante; não conhecia os policiais, antes desse dia; resolveu dar o recado, sem pensar que estivesse fazendo algo errado; o policial deu um tiro no sentido de onde estava, e quase pegou na sua perna; confirmou que foi ouvida em audiência de custódia, e diz que não relatou isso em audiência de custódia; não foi questionada naquela ocasião se houve algum problema com a conduta dos policiais; é mentira dos policiais que estava conversando com os policiais, nunca tinha visto ele antes; disse para ele "sai daqui", "sai da minha janela", porque sua casa estava como ponto de drogas; sabe disso porque, quando houve prisão anteriormente, os policiais foram até lá, quando foram prender um rapaz, e foram num outro prédio; vende latinhas, outras pessoas a ajudam, mas os traficantes nunca lhe deram um centavo; questionada sobre seu interrogatório em solo policial, responde que deu água para Neythan, mas nada recebia em troca; questionada sobre ter falado que Neythan levava drogas para o local, respondeu que "não", que "não sabia quem era o gerente"; sabe que quem leva drogas é o gerente porque os policiais falam; questionada sobre ter afirmado a Neythan sobre a presença dos policiais naquele endereço, respondeu que foi o recado que o rapaz pediu para avisar; naquela ocasião disse a Neythan que o "vovô", que era o menino que lhe pediu para falar, tinha sido preso, e que os policiais levaram as drogas, apenas isso.

Diante desse quadro, resta concluir pela procedência parcial da pretensão punitiva.

Com efeito, as testemunhas policiais que depuseram em Juízo forneceram relatos firmes e detalhados das circunstâncias em que as drogas foram encontradas e dos fatos que levaram à prisão em flagrante dos acusados.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se evidenciado o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016.)

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação dos réus, no caso concreto.

Nesse contexto, apesar dos esforços da Ilustre Defesa, o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, não se podendo acolher a tese de absolvição.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Descabe a desclassificação para o crime descrito no artigo 37 da Lei de Tóxico. Ainda que se possa admitir que a ré atuava como "olheira", tem-se que, nessa função, participava diretamente da própria execução do delito, em divisão de tarefas, figurando, portanto, como coatora, o que não se confunde com a conduta prevista no art. 37 da Lei 11.343/06, de mero prestador de "informações".

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Ed. Forense, 8ª ed., pág. 367:

"... o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da

conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância”.

Sobre o tema o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça:

“Tráfico de entorpecentes. Agente que exercia a função de “olheiro”. Envolvimento não limitado a fornecimento de informação isolada a traficante. Coautoria ativa e intensa no comércio ilícito de entorpecentes. Desclassificação para a conduta prevista no art. 37 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Em se cuidando de agente que exercia a função de “olheiro”, ostentando envolvimento não limitado a mero fornecimento de informação isolada a traficante, mas sim verdadeira coautoria ativa e intensa no comércio ilícito de entorpecentes, não se cogita de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 37 da Lei n. 11.343/06” (Apelação Criminal nº 1500948-14.2020.8.26.0535, Rel. Des. Grassi Neto, j. 29.10.20).

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância" (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência.

Também entendo que não restou comprovado de forma segura o envolvimento de adolescente, tendo em vista que ele não foi apreendido para se verificar a sua idade; os depoimentos dos policiais de que seria um adolescente pela voz e pelo porte físico não são suficientes para caracterizar a causa de aumento de pena. Por fim, quanto ao crime de associação, também não há provas suficientes dos elementos caracterizadores, como estabilidade e continuidade da atuação dos réus, devendo ser absolvidos de tal imputação.

Passo à dosimetria da pena.

NEYTHAN JACINTO DE ANDRADE

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena fica mantida.

Na etapa derradeira, possível a redução descrita no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado ostenta bons antecedentes, não há nos autos indicação de que o integre organização criminosa e, ainda, a quantidade de droga apreendida, diminuo as penas em 2/3, de modo que as fixo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira dos réus, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

VALDINÉIA SILVA CARDOSO

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena fica mantida.

Na etapa derradeira, possível a redução descrita no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a acusada ostenta bons antecedentes, não há nos autos indicação de que o integre organização criminosa e, ainda, a quantidade de droga apreendida, diminuo as penas em 2/3, de modo que as fixo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para condenar NEYTHAN JACINTO DE ANDRADE e VALDINÉIA SILVA CARDOSO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no mínimo legal.

Substituo em favor dos réus, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, do Código Penal, e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade e ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, conforme artigo 46 do Código Penal.

Assistidos pela Defensoria Pública, concedo aos réus os benefícios da justiça gratuita.

Tendo em vista o regime imposto, poderão os réus recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas e remanescentes nos autos, a ser realizada na forma prevista na Lei n. 11.343/06. Sem prejuízo, decreto o perdimento dos demais bens e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Guarulhos, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA